

1500355-43.2021.8.26.0472

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500355-43.2021.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500355-43.2021.8.26.0472

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON WILLIAN GONÇALVES DA CRUZ

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de ROBSON WILLIAN GONÇALVES DA CRUZ, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal afirmando que em 07 de maio de 2021, às 02h20min, na rua João Procópio Sobrinho, nº 191, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, escalou e arrombou a porta do estabelecimento comercial chamado "Loja do Felipe" e subtraiu, para si um celular Samsung S7 cor preta, um celular Apple Iphone 7 Plus cor branca, dois display (telas) de Iphone X na cor preta e um notebook HP cor branca, objetos estes avaliados em R\$ 7.000,00.

Segundo narrou denúncia, "o denunciado - multirreincidente específico no crime de furto (fls. 81/84) - dirigiu-se à "Loja do Felipe", que realiza conserto de celulares e, aproveitando-se da menor vigilância durante o repouso noturno, ingressou no imóvel mediante escalada e arrombamento da porta do corredor lateral (cf. laudo pericial às fls. 127/132). Na sequência, ROBSON subtraiu os aparelhos celulares e componentes eletroeletrônicos acima descritos, empreendendo fuga.

Contudo, durante a prática delitiva o alarme da loja foi acionado e seu proprietário, Luis Filippe Alves de Oliveira Barbosa, ao verificar remotamente o sistema de câmeras, constatou a presença do denunciado no local, tendo de pronto para lá se deslocado. Chegando no local, Luis Filippe avistou o denunciado há cerca de trinta metros de distância, o qual, ao perceber a aproximação daquele, fugiu

abandonando os dois displays (telas), o celular Samsung e o Notebook HP. Na sequência, Luis Filipe acionou a Polícia Militar informando a direção de fuga do denunciado, tendo os agentes obtido êxito em capturá-lo ainda na posse do celular Apple Iphone 7 Plus. Os objetos foram apreendidos, avaliados e devolvidos à vítima (cf. autos às fls. 05/04 e 115/116), bem como o local foi periciado, constatando-se a escalada e rompimento de obstáculo (cf. laudo às fls. 127/132)".

A denúncia foi recebida e o processo seguiu com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento. Foi instaurado incidente de insanidade mental e, após, as partes apresentaram alegações finais por meio de memoriais escritos..

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto:

Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores (...)

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

STJ, Terceira Seção, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos.

O entendimento firmado no Tema 934 apenas seguiu a jurisprudência do STF. No julgamento do RE 102940, o voto do relator, Min. Moreira Alves, direcionou-se para igualar o marco temporal da consumação do delito criminal com o delito civil (vício da posse), por isso, o repetido termo "inversão da posse". Nesse sentido é válida a lição do Desembargador Francisco Loureiro sobre a cessação da clandestinidade:

A posse é clandestina (clam) quando se adquire via processo de ocultamento em relação àquele contra quem é praticado o apossamento (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. Cit., p. 23). É um defeito relativo: oculta-se da pessoa que tem interesse em retomar a posse, embora possa ser ela pública para os demais. Na violência, retira-se o poder de reação do possuidor, que conhece a agressão à sua posse. Na clandestinidade, o possuidor não percebe a violação de seu direito, e por isso não pode reagir. Questão relevante é saber se para cessar a clandestinidade deve o esbulhador ter ciência inequívoca de que a coisa acha-se nas mãos do possuidor injusto ou, em vez disso, basta que o novo possuidor não mais oculte sua conduta. O melhor entendimento é que não há necessidade de que a vítima tenha efetivo conhecimento do esbulho, mas que o esbulhador torne possível à vítima conhecê-lo (Pinto, Nelson Luiz. Ação de usucapião. São Paulo, RT, 1987, p. 107-8). Torna-se pública a posse quando nasce para a vítima a possibilidade de conhecer o esbulho. Loureiro, Francisco Eduardo. Código civil comentado. 8ª ed., Barueri, Manole, 2014, p. 1070.

Portanto, considera-se invertida a posse a partir do momento em que se torna possível à vítima saber do ocultamento; momentos posteriores, como a fuga com a

coisa em seu poder, na esteira do já explicitado pelo Min. Moreira Alves, são mais do que suficientes para atestar a consumação.

Ficou comprovada a existência do crime e sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, pelo auto de avaliação de fls. 04/05 e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A vítima, Luis Filipe Alves de Oliveira Barbosa, na fase policial, disse que "é proprietário da loja de manutenção de celulares Loja do Felipe. Informa, que nesta data se encontrava em casa quando o alarme da loja disparou e ao verificar o sistema de câmeras constatou que havia um indivíduo no interior da loja. Esclarece, que ao chegar na loja avistou um indivíduo a 30 metros do local que ao perceber a aproximação fugiu abandonando dois displays de celulares, um celular Samsung e um Notebook HP. Declara, que acionou a polícia militar e informou a direção de fuga do suspeito, após a captura foi recuperado um celular Apple com o suspeito". Em juízo manteve sua versão. Porta dos fundos foi arrombada. Foram subtraídos notebook, telas de celular, dois celulares (um Samsung e um Apple). Na fuga, no entanto, ROBSON somente levou o celular da Apple. Celular Apple foi recuperado. ROBSON não estava legal, chegou até a passar mal (mas não soube declinar a causa). ROBSON foi capturado perto do ginásio de esportes. Viu ROBSON passando mal, mas estava consciente.

A testemunha de acusação, o policial militar, Anemias Duarte de Jesus, na fase pré processual, disse que "efetuava patrulhamento de rotina quando foi acionado para atender ocorrência referente a furto em andamento. Esclarece, que munidos das características e direção tomada pelo suspeito efetuaram diligências na Avenida Angelo Ramos, onde foi abordado o indivíduo posteriormente identificado como Robson Willian Gonçalves da Cruz; efetuada a busca pessoal foi localizado um celular APPLE com o suspeito. Ao ser inquirido o indivíduo admitiu que havia adentrado uma loja de celulares e praticado o furto, ao retornarem ao local do fatos o proprietário informou que ao ser alertado, pelo sistema de alarmes que haviam ingressado na loja, surpreendeu o suspeito a uns 30 metros do local e que ao perceber a chegada dele fugiu abandonando 2 displays de celulares, um notebook e um celular SAMSUNG". Em juízo manteve sua versão. Felipe lhe disse que chegou no local e presenciou alguém saindo da loja com os pertences na mão. Felipe declinou as características da pessoa que avistou. Capturou ROBSON na Angelo Ramos, o qual confessou o delito. ROBSON estava cansado de ter corrido bastante, mas não apresentava alterações de consciência. Não se recorda de ROBSON ter passado mal.

A testemunha de acusação, o policial militar, Tiago Marcelo Freire, na fase pré processual, disse que "nesta data foi acionado para atender ocorrência relacionada a furto em andamento em uma loja de celulares. Informa, que na Avenida Angelo Ramos surpreenderam um indivíduo suspeito com um celular APPLE. Ao ser inquirido o agente admitiu que havia adentrado e furtado o celular da loja". Em juízo manteve sua versão.

ROBSON WILLIAN GONÇALVES DA CRUZ, em declarações perante a autoridade policial, exerceu o seu direito de permanecer calado e manifestar-se apenas em juízo. Em juízo disse ser culpado. Toma remédio controlados até na penitenciária. Fez uso de drogas e álcool naquele dia. Passou, viu a porta arrombada e fez a subtração. Deu conta do que fez quando estava sendo algemado. De 2017 pra cá está passando entre a cadeia e a rua. Queria uma oportunidade porque não tem conseguido superar. Sempre trabalhou registrado. Tem uma índole boa. Até sua família está se afastando dele. Está envergonhado. Já foi internado uma vez.

A prova técnica conclui pela imputabilidade do acusado.

Independentemente de o acusado ter confessado os fatos, a prova oral trazida pela acusação foi uniforme e coerente, amparado por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a

denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Qualificadora do rompimento ou destruição de obstáculo (artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal): para sua caracterização é necessário que a violência seja praticada contra o obstáculo que dificulta a subtração e não contra a própria coisa. Nos termos do art. 171 do Código de Processo Penal é expressamente exigida a perícia, a qual, entretanto, conforme jurisprudência, pode ser substituída por provas testemunhais quando os vestígios tiverem desaparecido.

No caso em exame, houve arrombamento da porta metálica conforme laudo de fl. 127/132.

Qualificadora da escalada (artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal): considera-se escalada a entrada por via anormal, que exige um esforço fora do comum do agente para que se concretize a ação delitiva. Nos termos do art. 171 do Código de Processo Penal é expressamente exigida a perícia, a qual, entretanto, conforme jurisprudência, pode ser substituída por provas testemunhais quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. No caso, ela ficou comprovada pelo laudo de fl. 127/132; o que ficou provável ali foi somente o local por onde a escalada se deu. É suficiente para a comprovação da qualificadora o apontamento de que o obstáculo mais baixo era de 1,80m.

A existência de sistema de segurança e de vigilância eletrônica não torna o crime impossível, conforme entendimento do STJ:

Recurso especial representativo de controvérsia provido para: a) reconhecer que é relativa a inidoneidade da tentativa de furto em estabelecimento comercial dotado de segurança e de vigilância eletrônica e, por consequência, afastar a alegada hipótese de crime impossível; b) julgar contrariados, pelo acórdão impugnado, os arts. 14, II, e 17, ambos do Código Penal; c) determinar que o Tribunal de Justiça estadual prossiga no julgamento de mérito da apelação.

REsp 1385621/MG, Rel. Min. Rogerio Shietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015. Tema 924 dos Recursos Repetitivos.

Súmula 567 do STJ. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

Lembrando que a recuperação do bem não influi na avaliação da insignificância.

A devolução do objeto furtado à vítima não constitui, por si só, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.

STJ, AgRg no AREsp 1203702/SP, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018.

Configurado, assim, o delito de furto qualificado, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa".

Passo a dosar as penas.

Ressalto que a fixação dos aumentos da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei. Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima gera outra

injustiça. Percebe-se que em alguns casos a qualificadora somente aumenta a pena máxima; é o que ocorre, a título de exemplo, com a lesão simples no âmbito da violência doméstica. Ora, calcular os aumentos tendo por parâmetro a pena mínima é ignorar o comando legal que deu especial gravidade ao delito cometido naquela situação específica.

Sem contar os casos em que o intervalo de pena é menor que a pena mínima (§3º do art. 302 da Lei 9.503/97, artigos 267, 270 e 273 do Código Penal, entre outros), quando a utilização somente desta causa considerável prejuízo ao réu.

As situações e razões aqui trazidas são suficientes para demonstrar que a fixação da pena na primeira fase levando em conta somente a pena mínima contraria a lei e o sistema de imposição de sanções por ela previsto.

Ora, como o legislador estabelece sempre um mínimo e um máximo, ambos são a medida legal da gravidade do delito, de modo que o procedimento mais adequado para perceber essa grandeza em sua inteireza é levar em consideração justamente o intervalo de pena, ou seja, a diferença entre o máximo e o mínimo legal; aplica-se o aumento sobre o intervalo, adicionando a pena mínima.

É o que recentemente vem fazendo o STJ:

Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a exasperação da base em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias ordinárias, suficiente à prevenção e reprovação do crime.

STJ, AgRg no AREsp 1194509/MG, Quinta Turma, rel. Min. José Ilan Paciornik, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

A gravidade concreta do delito, praticado por pessoa que é integrante da polícia militar e que mais do que qualquer outro servidor público deve primar pela respeitabilidade de sua instituição e preservar o pundonor que rege a caserna; bem como o modo de execução, tratando-se de delito praticado por meio de grave ameaça e violência moral, justificam a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, que vai de 2 anos a 8 anos de reclusão.

STJ, AgRg no REsp 1678420/PA, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018.

Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, pois, considerando a fração de aumento ideal de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento da reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no decreto condenatório.

STJ, HC 448811/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

Quanto aos maus antecedentes, descabe falar em desproporcionalidade no aumento da pena em 6 meses, considerando a presença de dois títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, assim como o intervalo do apenamento estabelecido no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. STJ, HC 451487/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.

Mantém-se a valoração negativa das vetoriais analisadas pelo v. acórdão impugnado, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, descabendo falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, considerando o critério ideal de aumento por circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 6 anos.

STJ, HC 446462/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

É também a posição do Plenário do STF:

Ausente a alegada desproporcionalidade entre os parâmetros utilizados na dosimetria das penas dos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, sobretudo porque se tratam de delitos cujas objetividades jurídicas são distintas e que apresentam diferentes intervalos penais nos respectivos preceitos secundários.

AP 470 EDj-sétimos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 05/09/2013, DJe 10/10/2013.

Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização.

AP 470 EDj-vigésimos quartos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 28/08/2013, DJe 10/10/2013.

Aliás, em ações de competência originária das cortes superiores a dosimetria no intervalo da pena é uma constante.

Por exemplo, nos dois títulos penais condenatórios emitido pela Suprema Corte em 2019 (AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019, e AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020) nota-se claramente este procedimento (grifos nossos - diversos do original):

13.a.1) Quanto ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de três anos de reclusão e máxima de doze anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

13.b.1) Relativamente ao crime de empréstimo vedado (art. 17 da Lei 7.492/1986) (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de dois anos de reclusão e máxima de seis anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019.

No juízo de individualização da pena à luz do caso concreto, anoto que a sanção cominada de forma abstrata ao crime de lavagem de dinheiro é de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, nos termos do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998.

(...) fixo-lhe a pena-base, para cada delito de lavagem de dinheiro, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020.

A dosimetria foi adotada por unanimidade pelos dois colegiados, conforme extratos de ata.

Não diverge a Segunda Turma do Pretório Excelso. Na condenação em ação penal originária (AP 644/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 16/03/2018) assim se pronunciou:

(...) deve-se observar as penas originalmente cominadas, “reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa” (...) Considerando a particular gravidade das circunstâncias mencionadas, estabeleço a pena-base em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em sentido idêntico a Corte Especial do STJ (APn 327/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018):

Os fatos narrados ajustam-se aos elementos configuradores do delito de peculato-

desvio (art. 312, 2ª parte do Código Penal). (...)

Portanto, diante destas três circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Assim, sopesadas tais circunstâncias e observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Observar no voto acima que o aumento na pena corporal é idêntico ao da pena de multa, caso se considere o intervalo das penas (30% dos intervalos).

Tampouco se faz aqui tarifação de aumentos em tabelas predeterminadas. Além de não haver respaldo legal, isso fere de morte o espírito do Código Penal que estimula a valoração concreta dos elementos do caso.

Não se há falar em tabelamento das reprimendas, nem mesmo em institucionalização da pena mínima.

TJSP, Apelação n. 0000142-53.2017.8.26.0472 , 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Costabile e Solimene, j. 23.08.2018.

Preambularmente, lembro que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base.

AP 996/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018, DJe 08/02/2019.

Segundo o procedimento que valora cada circunstância judicial com um aumento de 1/6 ou 1/8, merecerá a reprimenda máxima o fato criminoso em que estiverem presentes todas as circunstâncias, pouco importando as suas gravidades, ao passo que um fato criminoso envolto em somente uma circunstância negativa, mas presente em um grau absurdo, sofrerá um aumento mínimo.

Ora, isso é uma má interpretação sobre o sistema de imposição de penas estabelecido pela Reforma de 1984 e um descumprimento da Constituição na medida em que esta impõe a individualização da pena, a qual necessita uma valoração da gravidade concreta das circunstâncias, e o art. 59 do Código Penal exige que a fixação da pena atenda à finalidade de reprovação e prevenção do crime, o que também não se alcança com tabelamentos.

Como diz Roberto Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na sua dureza. Nas mãos dos juizes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais são frios e autoritários. Para o homicídio – de 12 a 30 anos. Por quê? Para quê? Com a liberdade dos juizes responsáveis, não somente em atenção a circunstâncias convencionalmente enumeradas, e sim à realidade integral de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser salutar".

Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas, age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.

Portanto, o grau do aumento depende mais da intensidade concreta das circunstâncias que da extensão com que são encontradas.

Não se nega, contudo, que alguns julgadores ainda se valem do antigo método da pena mínima e do tabelamento de aumentos. Todavia, agindo contra toda a jurisprudência dos tribunais superiores, é dever justificar a heterodoxia.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que o acusado possui mais antecedentes (autos 0003958-39.2016.8.26.0129), razão pela qual elevo a pena em um sexto. Na mesma dimensão o aumento decorrente do valor dos bens, de considerável monta ao pequeno comerciante.

Comprovada a circunstância da escalada, pela qual a lei confere especial gravidade ao delito dobrando a sua faixa de pena, e bastando a circunstância do rompimento de obstáculo para qualificar o furto, aumento a pena em mais dois anos e 116 dias-multa. Fixo a pena-base em seis anos de reclusão e 243 dias-multa.

Segunda etapa. Presente a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência (certidão de antecedentes de fls. 81/84, autos 0000605-92.2017.8.26.0472 e 1500009-29.2019.8.26.2019.8.26.0160). Prevalece a última implicando um aumento de 1/6 (um sexto), resultando em sete anos de reclusão e 283 dias-multa.

Terceira etapa. A causa de aumento do repouso noturno verifica-se quando o ato é cometido entre o pôr e o nascer do sol, seja o local residência ou estabelecimento comercial (AgRg no REsp 1.251.465 – MG, rel. Min. Gilson Dipp, 2.10.2003), mesmo quando desocupados ou inabitados (STJ HC 29153 – MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 4.2.2014), e aplica-se a todas as figuras do furto, seja ele simples, privilegiado ou qualificado (ver STF HC 130952/MG, rel. Min. Dias Toffoli, 3.5.2016, e Nucci, Código Penal comentado, glosa 14 ao art. 155). No caso, o crime de furto foi realizado às 02h20min, incidindo o aumento de 1/3 (um terço).

A reincidência e a negativa das circunstâncias judiciais exigem o regime fechado.

Todavia, em função do extenso tempo de custódia cautelar, possível a fixação, desde já, de regime semiaberto.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR ROBSON WILLIAN GONÇALVES DA CRUZ à pena de reclusão, pelo prazo de nove anos e quatro meses, em regime inicial semiaberto, bem como a 377 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e II, do Código Penal.

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado, as razões de sua prisão cautelar estão mantidas.

3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".
(...)

5. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes. STJ, Sexta Turma, RHC 86.384/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

Condene o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 27 de abril de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA